

1507956-56.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1507956-56.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507956-56.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO SOUSA FARIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

LEANDRO SOUSA FARIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, "caput" do Código Penal, pois segundo apurado no dia 31 de março de 2021, por volta das 14h55min, na Avenida Yervant Kissaajikian, nº 3384, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca, em época de calamidade pública, subtraiu para si 32 (trinta e dois) frascos de desodorante da marca Rexona, avaliados em R\$ 427,18 (quatrocentos e vinte e sete reais e dezoito centavos) - auto de avaliação de fls. 08, pertencentes à empresa vítima Supermercado Nações Unidas Ltda., nome fantasia RICOY.

A denúncia foi recebida, o acusado foi citado pessoalmente em cartório, notificado, (fls. 178) e apresentou sua resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, não sendo o caso de suspensão condicional do processo ou de acordo de não persecução penal, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidos dois policiais. O réu não foi encontrado no endereço por ele fornecido e em razão disso foi declarado revel, nos termos do disposto no art.367, do Código de Processo Penal.

As partes desistiram da oitiva da vítima faltante, o que foi devidamente homologado em juízo.

Encerrada a instrução em seus memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado pela prática de furto simples em sua forma tentada.

A Defesa, por sua vez, buscou a absolvição do réu e em caso de eventual condenação requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da agravante da

pandemia e ainda o estabelecimento de regime menos gravoso para o cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade delitativa restou comprovada, além da prova oral produzida em Juízo, pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e entrega dos cosméticos subtraídos.

A autoria também é inconteste.

O representante legal do supermercado vítima, ouvido em sede policial alegou que trabalhava como fiscal de loja no supermercado Ricoy, e que havia acabado de iniciar seu turno de trabalho quando percebeu que um indivíduo estava se comportando de forma suspeita, aparentemente colocando produtos dentro de uma sacola de feira.

O indivíduo então se dirigiu para a saída do estabelecimento e passou pelos caixas sem pagar por nada e em razão disso saiu ao seu encalço e conseguiu alcançá-lo no estacionamento e pediu para olhar dentro da referida sacola e lá encontrou 32 desodorantes, produtos estes que totalizavam o valor de R\$ 427,18 (quatrocentos e vinte e sete reais e dezoito centavos). Pediu então que o indivíduo apresentasse a nota fiscal daqueles produtos e neste momento o indivíduo admitiu que havia subtraído os produtos de dentro do mercado. Assim ligou 190 e pouco depois os policiais chegaram e prenderam o indivíduo.

As alegações de P.H.S. de S., embora prestadas somente em sede administrativa, vieram devidamente corroborada pelos depoimentos dos dois policiais militares ouvidos em audiência.

Com efeito, o policial Higor Silva Santana relatou que foi chamado para atender furto em estabelecimento. Chegando lá, o réu já estava detido e segundo informações dos funcionários do local o réu teria subtraído produtos de dentro do supermercado e foi abordado e detido, já na rua.

No mesmo sentido, o outro policial, após Jackson Torres Gomes, ao ser ouvido em juízo, após prestar o compromisso de dizer a verdade, narrou que juntamente com seu colega de farda foram chamados para atender um furto em estabelecimento comercial e no momento em que chegaram ao local o réu já estava detido pelos funcionários do supermercado. Afirmou, ainda que o réu ao ser indagado sobre os fatos, acabou confessando que havia sido pego após se apoderar de vários desodorantes.

O réu por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio e não foi encontrado no endereço fornecido e assim não pode ser ouvido em juízo, sendo declarado revel.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas outra solução não há que a condenação do acusado.

Isso porque, nos casos de crime contra o patrimônio, de fora parte o problema do exagero da vítima ao descrever a atuação do agente, o normal é inexistirem razões para querer mentir. Assim, a preocupação do juiz deve limitar-se à pesquisa da existência de algum motivo especial capaz de levar aquela a apontar falsamente a ré como autora do crime ou de descrever com exagero a atuação da agente.

À condenação por furto basta que a declaração da vítima esteja em harmonia com os demais elementos dos autos, que seja confirmada por qualquer outro dado.

Releva notar, neste passo, ainda, que a palavra da vítima, ainda que colhida somente na fase administrativa, deve merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teria ela proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado. Aliás, esse entendimento é reiterado na jurisprudência: JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97.

Lembra-se, aqui, trecho da lição do clássico NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA, que espanca qualquer dúvida a respeito de eventual suspeita da palavra do ofendido: "A

animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido, nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque tu, como ofendido, tem ódio contra ele -, é uma verdadeira e flagrante contradição; é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui" (cf. tradução brasileira, págs. 409-10).

Ademais, Não se pode olvidar, como pacificado na doutrina e da jurisprudência que, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TACrimSP, 10ª Câm., Ap. 250.141, rel. Juiz PENTEADO DE MORAES, in JTACrimSP, 66/410). Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena.

O réu é reincidente, específico, já tendo sido definitivamente condenado pelo crime de furto perante a 3ª Vara Criminal de Diadema, autos nº 0006190-59.2015.8.26.0161, o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Se não bastasse isso, já foi condenado definitivamente pela prática de outros quatro delitos, todos eles contra o patrimônio, autos nº 0045981-43.2016.8.26.0050; autos 0011114-87.2017.8.26.0050, autos 0031658-.2017.8.26.0050 e autos 0062744-66.2009.8.26.0050, conforme se depreende das certidões de fls. 75/81, demonstrando que tem maus antecedentes e personalidade voltada para o crime, assim sendo, não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo a pena ser aumentada em 1/3, chegando-se ao patamar de perfazendo, 01 ano, 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Não há que se falar em desconsideração das condenações acima apontadas apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, de fato, se por um lado elas não podem mais serem consideradas como agravantes em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de considerá-las como maus antecedentes, já que demonstram a personalidade criminosa do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

STJ- "condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes" (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, "não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência" (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos Veloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

"Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Neste ponto, cumpre registrar que o período depurador consignado no artigo 64, inciso I, da lei penal substantiva, diz respeito única e exclusivamente ao regramento da reincidência, não se estendendo aos maus antecedentes - sobretudo porque tal particularidade também serve para extremar os dois conceitos.

Aliás, em sede de repercussão geral - Tema 150 -, o plenário do Pretório Excelso, em sessão virtual realizada de 7.8.2020 a 17.8.2020, apreciou a matéria e fixou tese segundo a qual "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o

prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

Ademais, não procede a tese defensiva no sentido de que as condenações pretéritas que não se enquadram no conceito de reincidência, nada representam. Um indivíduo que ostenta duas condenações anteriores, evidentemente, não pode receber o mesmo tratamento penal que é dado a um primário, o que seria uma ofensa ao princípio da individualização das penas.

Portanto, condenação criminal anterior ao fato em análise que se enquadra no período depurador é reincidência, e as que não se enquadram são maus antecedentes, entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça: “As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes. Precedentes.” (STJ - AgRg no HC 532046 / RJ - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - DJe 05/06/2020).

A Súmula 241 do STJ prevê a vedação ao Magistrado de considerar um único fato (condenação definitiva pela prática de crime) para, ao mesmo tempo, reconhecer maus antecedentes e reincidência, exasperando a pena nas duas etapas de aplicação, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido foi entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) “Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase da dosimetria, configurar a reincidência, e, na primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob pena de bis in idem”. (HC 598.460/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Veja-se, ademais, que a expressão “muito antigas”, utilizada para, por vezes, requerer o afastamento das condenações, é imprecisa e pode por vezes levar a situações de injustiça e até de quebra do princípio da individualização da pena, devendo o critério do julgador ser objetivo e fundado em fatos concretos, como os aqui apontados.

Na segunda fase, respeitado entendimento diverso, há que se considerar que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do Corona vírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020. Ademais, respeitadas posições em contrário, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Veja-se que na época dos fatos, ainda não havia vacina disponível para todos e a única forma de se tentar conter a doença que se propagava e estava mantendo milhares de pessoas era o isolamento social.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

“Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos” (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: “(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro

adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias." (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020- "O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença", escreveu o magistrado em seu voto. "De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior

reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - "(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública" (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020).

TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020).

Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

9ª Câmara Criminal - Des. Fátima Gomes: "Com efeito, na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, encontra-se previsão para a agravação da pena diante de circunstâncias que representem o aproveitamento por quem realiza o crime da existência de uma situação de perigo comum. Cabe notar não ser necessário que o sujeito crie a situação de perigo, mas que apenas a aproveite. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias. Na situação especial, o apelante aproveitou-se de acontecimentos de especial relevo para a vida da população. O acontecimento e seus efeitos maléficos devem, obrigatoriamente, ser conhecidos por quem deles conscientemente aproveita-se.

Nesse sentido: "Essa circunstância implica maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso se revela mais provável. É necessário que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevalecer-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua impunidade." (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: Jurisprudência, Conexões Lógicas com os Vários Ramos do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 335).

Assim, referida agravante tem natureza objetiva, estampada no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e, diante da notória calamidade pública gerada pela pandemia do vírus covid-19, mostra-se absolutamente desarrazoada a pretensão defensiva de afastá-la".

Também é o caso de se reconhecer a agravante da reincidência atestada nos autos, e assim a pena deve ser majorada em mais 1/5, chegando-se a pena de 01 ano, 07 meses e 06 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Na terceira fase não há causas de aumento de pena a se considerar.

O crime, contudo foi tentado já que o réu não conseguiu subtrair os bens após já tê-los colocado dentro de uma sacola e saído do estabelecimento comercial sem ter efetuado o devido pagamento, em face da ação do funcionário da empresa vítima que ao perceber sua atitude conseguiu apreendê-lo, com os objetos nas mãos, no estacionamento do referido supermercado.

Assim sendo, considerando o iter criminis percorrido pelo réu, a pena deve ser diminuída no mínimo legal de 1/3, e ser fixada em 01 ano e 24 dias de reclusão e 10 dias-multa.

No mais, como não há nos autos provas da condição econômica do acusado, fixa-se o dia multa no mínimo legal estabelecido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra o réu para condená-lo à pena de 01 ano e 24 dias de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, por estar incurso no art. 155, "caput", do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado pois se ajusta e convém a acusado. Trata-se de acusado já condenado por outros crime contra o patrimônio e que ao se ver solto, novamente voltou a delinquir, demonstrando assim, por ora, que só o cárcere lhe é conveniente.

Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontrastável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RTJ 123/547).

Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do CP. (cf., exemplificativamente, ac. un. na Ap. nº 673.255/1, de São Paulo).

"Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP)" (STJ, AgRg no HC 490.175/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/05/2019, Dje 11/06/2019).

Nessa mesma linha: "No caso, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem destacaram, expressamente, que o paciente possui maus antecedentes. 4. Apesar de a pena final do agravante ter sido estabelecida em patamar inferior a oito anos de reclusão, o fato de o acusado possuir circunstância judicial desfavorável, a qual afastou a pena-base do mínimo legal, impede o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal, devendo ser mantido o regime inicial fechado estabelecido pelo acórdão da origem" (STJ, AgRg no HC 477020/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, jg. 16/05/2019),

Os motivos que foram levados em conta para a fixação da pena, a reincidência e ainda o regime fechado para início de cumprimento, não favorecem o acusado, pois já foi condenado a pena restritiva de direitos e novamente se pôs a delinquir, demonstrando que o réu não faz jus a novo benefício.

Como é sabido, não basta que o acusado satisfaça os requisitos objetivos da lei para ter sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, é necessário, também que os requisitos subjetivos lhe sejam favoráveis. Nesse sentido, a jurisprudência: "Eventual substituição da pena de privação de liberdade por restritiva de direitos, bem como a estipulação de regime prisional, estão a depender da análise articulada das circunstâncias subjetivas dos pacientes, as quais, in casu, foram inteiramente desfavoráveis".

Sendo também inviável a aplicação do sursis consoante disposto no art. 77, também

do Código Penal.

Contudo, tendo permanecido solto durante toda a instrução criminal e não havendo pedido expresso, ou mesmo demonstração de que estão presentes os requisitos autorizadores de sua prisão cautelar nesta oportunidade, poderá recorrer desta em liberdade.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes. Com a juntada dos cálculos aos autos abra-se vista às partes para a devida ciência e eventual manifestação.

Comunique-se a vítima, consoante disposição legal.

Condene ainda o réu ao pagamento das custas judiciais, que decorre de expressa previsão legal. Com efeito, o Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Ressalta-se que caso demonstre preencher a hipótese legal, poderá o réu valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, Dje 14/06/2011).

E ainda, Apontamento de JÚLIO FABBRINI MIRABETE não destoa, registrando-se que "Estão as custas a cargo do vencido. A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, diz o artigo 804. Sendo dois ou mais os réus condenados, a satisfação das custas deve ser efetuada por rateio (pro rata). Não sendo satisfeitas no processo penal as custas pelo condenado, ficará sujeito ele à cobrança judicial pelas vias próprias. A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas, pois a exequibilidade ou não da sua cobrança é matéria de execução e nesta deve ser considerada" (Processo Penal, 17ª ed., Atlas, 2005, pág. 823, nº. 21.3.1).

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA